

1524784-30.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... a não ser para a prática de tráfico de drogas ou uso de drogas (logicamente com exclusão das pessoas que para lá se dirigem com objetivo de fazer trabalhos sociais e bem como os agentes públicos).

No caso das rés, a suspeita recaiu na prática do tráfico de drogas. E a fundada suspeita estava bem lastreada pelo contexto da situação na qual todos se encontravam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524784-30.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524784-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278030/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20774598 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3640/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2278030 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANE AGUIAR DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

ELIANE AGUIAR DA COSTA e VERÔNICA CRISTIANE GOMES DA SILVA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursoas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c.

Artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Elas teriam, no dia 12 de outubro de 2021, pela manhã, na Avenida Rio Branco, nº 964, Santa Cecília, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, trazido consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína na forma de "crack", pesando 162,8 g (cento e

sessenta e dois gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 1.691,00 (mil, seiscentos e noventa e um reais) em espécie (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudo de constatação de fls. 42/44).

Notificadas as rés (fls. 126 e 128), apresentou-se a defesa prévia (fls. 132).

Havendo justa causa a contuindade da ação penal, foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 134/138).

As rés foram citadas pessoalmente, fls. 156 e 158.

Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 5), o boletim de ocorrência (fls. 6/8), o auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), o laudo de constatação preliminar (fls. 42/44) e o definitivo (fls. 122/123).

Na data de hoje, foram ouvidos os Guardas Municipais e as rés interrogadas ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação das rés nos termos da denúncia. Quanto a pena, na primeira fase, nada a acrescentar. Em segunda, Verônica é reincidente específica. Há ainda a agravante da pandemia. A confissão de Verônica não pode preponderar sobre a agravante da reincidência específica. Em terceira fase, sem privilegio a ambas.

A defesa pleiteou, em tese principal, a absolvição das duas em razão da ilegalidade na abordagem da GCM porque não havia fundada suspeita conforme farta jurisprudência dos Tribunais Superiores. A materialidade delitiva também resta prejudicada ante a quebra na cadeia de custódia da prova. Prejudicada a materialidade delitiva, mais uma razão para a absolvição. Em caso de entendimento diverso, subsidiariamente requereu: a) pena base: seja estabelecida no piso legal ante as favoráveis circunstâncias judiciais; b) agravantes e atenuantes: seja afastada a agravante que consta da denúncia ante a ausência de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a pandemia de Covid19; quanto a Veronica, que a confissão seja integralmente compensada com a reincidência; c) causas de aumento e diminuição de pena: para Eliane, que seja aplicada a minorante do art 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, visto que a ré é primária, possui bons antecedentes, e não há provas que ela se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa; d) regime inicial de cumprimento de pena: seja estabelecido o aberto para Eliane, o que se pede diante do montante de pena aplicado, das favoráveis circunstâncias judiciais, da primariedade e do tempo de prisão provisória (desde 06/10/2021); e) substituição da pena: que a pena privativa de liberdade de Eliane seja substituída por restritivas de direitos, visto que o delito praticado não foi com violência contra a pessoa, a pena final do delito não ultrapassa o limite de 4 anos de reclusão; f) recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Pesem os argumentos trazidos pela douta representante do Ministério Público, razão assiste a Defesa quanto a quebra da cadeia de custódia da prova, o que trouxe duvidas quanto a materialidade do delito.

E somente por este motivo, entendo que a absolvição das acusadas é de rigor.

Assim, afasto a alegação de ilegalidade da atuação da Guarda Municipal em razão das buscas pessoas feitas nas acusadas que estavam no fluxo de movimentação da cracolândia.

Nesse sentido.

"Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a

notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Evidentemente que a fundada suspeita dos GCMs teve como razão de ser o fato das acusadas estarem saindo do interior do fluxo da cracolândia pois não há outro objetivo de se estar na cracolândia a não ser para a prática de tráfico de drogas ou uso de drogas (logicamente com exclusão das pessoas que para lá se dirigem com objetivo de fazer trabalhos sociais e bem como os agentes públicos). No caso das réas, a suspeita recaiu na prática do tráfico de drogas. E a fundada suspeita estava bem lastreada pelo contexto da situação na qual todos se encontravam envolvidos.

Contudo, a materialidade restou prejudicada.

Com efeito, já na delegacia, a Guarda Elisangela relatou a apreensão de duas pedras de crack, uma com Verônica e a outra com Eliane. É o que se depreende da análise de seu depoimento colhido a fl. 09. A Guarda Elisangela, já na delegacia, mencionou a apreensão de duas pedras de crack, uma com cada ré. Contudo, estranhamente, o B0 de fls. 6/8, o auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, a requisição de fls. 25 e os laudos de fls. 42/44 e 122/124 trazem a notícia de apenas uma pedra que foi periciada.

A denúncia também incorreu em equívoco na medida em que, ao mesmo tempo em que aduz que as corréas estavam na posse de uma pedra de crack com peso líquido de 162,8g, no corpo da peça exordial acusatória, o douto Promotor de Justiça menciona que Verônica estava na posse de uma pedra de crack e Eliane na posse de uma outra pedra de crack além do dinheiro apreendido com ambas.

Uma dessas pedras de crack, embora apreendida conforme mencionado pelos guardas municipais, não constou no auto de apreensão, fls. 23/24 e, portanto, não foi periciada.

Não houve explicação alguma no relatório final elaborado pela Autoridade Policial a respeito do fato. Aliás, o relatório também é contraditório pois, embora conste em um primeiro momento a apreensão de apenas uma pedra de crack em poder de ambas, na sequência faz menção a apreensão de duas pedras de entorpecente, uma com cada corré. Por fim, no próprio relatório, consta que apenas uma pedra foi remetida a perícia. É o que se depreende de fls. 80/81 como passo a transcrever:

"MM. Juiz,

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições constitucionais, por intermédio do Delegado de Polícia subscritor, orientada pelos princípios fundamentais do Estado de Direito, levando em conta a busca da verdade real, instaurou o presente Inquérito Policial diante da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Verônica Cristiane Gomes da Silva e Eliane Aguiar da Costa por suspeita de prática delitativa, em decorrência de sua prisão em estado flagrancial pelo crime de Tráfico de Drogas, após Guardas Civis as flagarem portando uma pedra mediada e fragmentos de substância aparentando ser crack e R\$ 700,00 (setecentos reais) em notas de cem, respectivamente, fato ocorrido às 09h30 de 12/10/2021, na Avenida Rio Branco, nº 964, sendo os entorpecentes constatados pelo laudo pericial nº 334995/2021, conforme mencionado no Boletim de Ocorrência nº 3640/2021, deste 2º D.P.

Compareceram os guardas civis informando que, no dia 12/10/2021, estavam em patrulhamento pela área do projeto redenção, quando por volta das 09h30, na Avenida Rio Branco, 964, avistaram duas mulheres, posteriormente identificadas por Eliane Aguiar da Costa e Verônica Cristiane Gomes da Silva, saindo juntas do fluxo que estava pela rua Helvetia, demonstrando certo nervosismo neste momento. Assim, a equipe as acompanhou até a Av. Rio Branco, um pouco mais afastado do fluxo e

decidiram por abordá-las. Em busca pessoal, com a Verônica foram encontrados uma pedra grande de substância aparentando ser crack e R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) em notas fracionadas. Com Eliane, foi encontrada uma pedra mediana e fragmentos de substância aparentando ser crack e R\$ 700,00 (setecentos reais) em notas de cem. Ao serem questionadas, as duas disseram que uma pessoa lhes entregou a droga e o dinheiro para levarem até um terceiro num local indicado, não sabendo informar quem são essas pessoas. Diante disto, deram voz de prisão e conduziram as suspeitas até o DP. Por fim, afirma que não foi necessário o uso de algemas.

As indiciadas, em audiência de apresentação e garantias, após serem científicas acerca de seus direitos, optaram por permanecer em silêncio e se manifestarem apenas em juízo.

As substâncias foram apresentadas e apreendidas e sendo encaminhadas para o exame de constatação preliminar ao Instituto de Criminalística de São Paulo - IC/CEAP. O Instituto de Criminalística de São Paulo confirmou que a substância apreendida é entorpecente na modalidade entorpecente: 162,8 gramas de COCAÍNA em pedra - Laudo IC/CEAP - Entorpecente nº 334995/2021, lacre 1657684 SPTC/SP atestada pelo Perito Criminal, Dr. Vinicius Felix Pacheco.

O dinheiro encontrado em posse das indiciadas foi apreendido e depositado em juízo. Diante dos fatos narrados e elementos sumariamente colhidos, considerando a constatação da substância entorpecente, consoante laudo supramencionado, somada aos depoimentos dos guardas civis, deixando claro que os entorpecentes estavam na posse das indiciadas e que quantidade de droga encontrada em posse delas está muito acima do esperado para um usuário, além da presença de uma alta quantia em espécie, deliberou o Delegado de Polícia signatário pela presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, em juízo preliminar de probabilidade, tipificando a conduta das conduzidas, Eliane Aguiar da Costa e Verônica Cristiane Gomes da Silva, no tipo misto alternativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, por incidir na ação "trazer consigo" ou transportar droga ilícita, em circunstâncias e quantidade que denotam a prática do tráfico de drogas, conduta em que presente o estado flagrancial nos termos do artigo 302, incisos I, do Código de Processo Penal e determinou a lavratura do presente auto de prisão em flagrante delito em desfavor das indiciadas, garantindo-lhe todos os direitos, constitucionais e legalmente estabelecidos, verificando-se a homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante decisão judicial constante nos autos.

Remeta-se ao 77º DP - Santa Cecilia, responsável pela área dos fatos.

São esses os fatos apresentados e apurados por esta autoridade policial, ora submetidos à apreciação de Vossa Excelência.

É o relatório."

Ou seja, o próprio relatório da autoridade policial quanto a apreensão do entorpecente é contraditório. Ora fala em uma pedra de substância entorpecente apreendida em poder das rés, ora fala em duas pedras de crack, uma apreendida com cada corré.

Por fim, ao mencionar o laudo de constatação provisória, menciona apenas a análise de uma pedra de crack.

Assim houve, de fato, quebra na cadeia de custódia da prova referente a materialidade do delito.

Penso que em uma ação penal por fato tão grave, sem a oitiva de outras testemunhas que não os agentes públicos, não pode haver falha desta natureza que, a meu ver, é grave a ponto de inviabilizar a condenação das rés porque demonstra, na melhor das hipóteses, total falta de zelo e organização, ao menos neste processo, no que se refere a custódia do entorpecente apreendido já que parte relevante dele simplesmente desapareceu sem deixar vestígios.

Com efeito, e como já observado, não há uma explicação plausível para o desaparecimento da segunda pedra de crack, a qual foi mencionada pela guarda civil em seu depoimento prestado em solo policial, devidamente confirmado por seu colega de farda, o qual limitou-se a ratificar o depoimento prestado por ela. Essa segunda pedra de crack também foi mencionada no histórico do Boletim de Ocorrência 3640/2021, fls. 06/08 e no relatório final da autoridade policial.

Ou seja, como é possível ter a certeza de que a pedra examinada em perícia foi a mesma pedra apreendida em poder das rés?

Com qual delas a pedra examinada foi apreendida?

Naturalmente que os guardas não souberam informar se a pedra que pesa 162,8g, devidamente periciada, foi apreendida com Verônica ou com Eliane.

E a segunda pedra, apreendida pelos GCMs mas que não constou em auto próprio? Era a maior ou a menor? Estava com Eliane ou com Verônica? Tratava-se de substância entorpecente já que não foi periciada?

Sobreleva notar que as rés confessaram o crime. Contudo a confissão de ambas não é o suficiente a lastrear uma condenação sem a prova da materialidade.

Veja-se, não se trata de ausência de lacre ou rompimento de lacre do entorpecente.

A quebra na cadeia de custódia trata da ausência de parte relevante do entorpecente apreendido, ou seja, ausência da materialidade de um crime que exige essa prova.

A seguir transcrevo a prova oral produzida no dia de hoje, vejamos:

Elisângela, guarda municipal, reconheceu as acusadas declarou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pela cracolândia e avistaram as duas rés saindo do fluxo de usuários saindo da Elçvétia. Passaram a observar as duas e ao chegarem na rua Rio Branco, ejetuaram a abordagem. Com Verônica encontrou uma pedra grande de crack e 900,00 em notas miúdas. Com Eliane uma pedra mediana e uns fragmentos de crack além de R\$ 700,00 em notas de R\$ 100,00. Elas admitiram que teriam recebido o entorpecente e o dinheiro de uma pessoa de dentro do fluxo e que iriam repassar a uma terceira pessoa ou a terceiras pessoas. Não disseram quem seriam essas pessoas. Elas não estavam tão sujas como os demais que estão em situações críticas e não aparentavam estar drogadas embora tenham dito que eram usuárias. Estavam tranqüilas e não foram algemadas. O dinheiro de uma delas estava no cós da calça e o entorpecente foi encontrado em busca pessoal e não em bolsas. Salvo engando a droga de uma delas estava na axila. Não as conhecia antes dos fatos.

O guarda Márcio reconheceu as rés de uma ocorrência relacionada a trafico de entorpecente nas proximidades da cracolândia. Observou que as duas saíam do fluxo de usuários. Ao perceberem a viatura aparentaram um certo nervosismo. Optaram por fazer a abordagem um pouco mais para frente para evitar problemas com os demais. Na busca pessoal as duas estavam com entorpecente e dinheiro. Elas disseram que estavam apenas no transporte da droga, e que não sabiam quem seria. Disseram que a droga seria entregue na avenida. Isso é comum, ou seja, os traficantes se utilizarem de usuários para fazer o transporte da droga. Não aparentavam ser moradoras de rua mas estavam fisicamente debilitadas. Não se recorda se elas admitiram ser usuárias. Não se recorda com detalhes onde o entorpecente foi localizado. Não as conhecia antes. Elas foram abordadas na avenida Rio Branco, a uns 70 metros do fluxo de usuários. Sabe que com uma delas encontrou 700,00 em notas maiores e com a outra novecentos e alguma coisa em notas mais fracionadas. O entorpecente apreendido era crack. Há uma base da policia militar há uns 70 metros mais para frente. Duas pedras de tamanho considerável foram apreendidas em poder de ambas sendo que algumas pedras já fracionadas, prontas para o uso. Não se recorda quem estava com a pedra maior.

Por fim, as rés confessaram.

Com efeito, Verônica declarou que tem 36 anos de idade. Tem 5 filhos que moram com os pais deles. Trabalha com reciclagem. Mora com o irmão mas também fica na cracolândia e as vezes passa a semana lá usando sua droga. Reconhece que estava com o entorpecente e com 90 reais. A pedra estava dentro de uma sacola e era uma pedra maior do que as que são utilizadas pelos usuários. Foi um tal de Negão quem pediu para levar a droga e o dinheiro até o hotel "Princewsinha". Na verdade não sabe quanto havia de dinheiro na sacolinha porque estava tudo junto. Para fazer esse serviço ia ganhar um pedaço de crack e 20,00. Com Eliane também foi apreendido 700,00 e um pedaço de crack. Ela ia entregar no mesmo lugar. Não viu Negão entregar nada a Eliane mas ele mandou que ela fosse ao mesmo lugar para onde iria a interroganda. Já foi condenada por trafico de drogas e por uso. Não chegou a ver a viatura ou os guardas. Não tentou correr em momento algum.

Eliane declarou que tem 33 anos de idade e tem 4 filhos. Dois já casados e os outros dois residem com a avó. Há 4 ou 5 anos não estava trabalhando, fazia

reciclagem ou as vezes fazia programa. Mora nas ruas, em uma barraca na princesa Isabel. Por causa do vício não reside com a mãe. Já teve uma passagem criminal mas não foi condenada. No dia dos fatos estava no fluxo fazendo reciclagem. Foi parada por "Fubá". No retorno da limpeza ele a parou, entregou o entorpecente e 700,00 em notas de cem e uma pedra do tamanho aproximado de uma laranja. Tinha que ir até o hotel Princesinha e lá entregaria o entorpecente a uma pessoa que não sabe quem seria. Ia ganhar duas pedras de crack ou R\$ 20,00. Foi presa pela Guarda. Foi abordada na entrada do hotel, na calçada. Não chegou a ver os Guardas Municipais ou a viatura. Fubá também entregou algo para Verônica mas não sabe o que foi. Embora confessas, a confissão limitou-se ao transporte de algo que foi entregue a ambas por um suposto traficante e que deveria ter sido entregue a uma terceira pessoa. Elas não confirmaram a que estavam vendendo droga. É verdade que disseram que tinham conhecimento do conteúdo, ou seja, que se tratava de entorpecente. Contudo, essas confissões não superam a falha na violação da cadeia de custódia traçada pelo Código de Processo Penal que deve ser sopesada pelo magistrado sentenciante com os demais elementos produzidos na instrução, derivando daí a falta de confiabilidade da prova.

Tenho conhecimento de que a condenação por tráfico de entorpecente prescinde da apreensão do entorpecente. É possível que, através de outros elementos de prova, a condenação pelo tipo penal seja possível.

Mas nestes autos a situação é diversa. Parte relevante do entorpecente, mencionado na denúncia quando expõe o fato criminoso atribuído as rés, acabou sendo extraviado, não se sabe onde, nem como ou porque. Nenhuma explicação plausível foi trazida a juízo a respeito desta falha gravíssima, a qual não se pode ignorar e que trouxe grave comprometimento da prova incriminatória.

Exatamente por estas razões, diante da falta de confiabilidade da materialidade do delito, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para ABSOLVER ELIANE AGUIAR DA COSTA e VERÔNICA CRISTIANE GOMES DA SILVA das imputações que contra eles constam na denúncia nos termos do arttigo 386, VII do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURAS CLAUSULADOS.

Oficie-se a Egregia Corregedoria da Polícia Civil com cópia desta decisão bem como, com a copia do Boletim de Ocorrência de fls. 6/8, depoimentos de fls. 9/10, auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de fls. 42/44, e relatório final de fls. 80/81 para as providencias cabíveis a espécie. Publicada em audiência.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA